

能性；第二，私募基金募集完毕后，行为人是否改变资金用途，是否将主要资金用于生产经营以外的活动；第三，在投资项目运营过程中，行为人有无明显不负责任的行为表现，是否采取最低限度的成本控制及风险管控措施，是否通过借新还旧填补资金缺口，有无抽逃资金行为；第四，投资期限届满或投资项目结束后，行为人是否有逃避返还投资款的行为表现。具体到本案中，某基金公司依法进行了私募基金管理人登记并对涉案基金进行了备案；吸收集资参与人投资后，确实按基金合同的约定开展了正常投资和经营活动，大部分资金投向真实存在的项目而不是用于个人挥霍；同时对集资参与人也有还本付息行为，截至案发本金兑付率达到70%以上，相关人员并无恶意逃避返还资金迹象；虽存在借新还旧情形，但尚不足以认定归还本息主要通过借新还旧实现。因此，生效裁判认定各被告主观上不具有非法占有目的，其行为构成非法吸收公众存款罪。

（二）非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的转化

非法集资活动是一个持续的动态过程。实践中，既存在自始即以非法占有为目的、以诈骗手段吸收资金的单一集资诈骗犯罪，也存在从非法吸收公众存款罪转化的集资诈骗犯罪。在非法吸收公众存款行为持续的情形下，二罪的分水岭在于行为人非法占有目的的产生，具体表现为对没有归还能力的明知。本案中，被告单位虽在涉案私募资金运营期间被注销私募基金管理人登记，但该登记仅为形式要件，是否登记不影响对其行为性质的认定。各被告在被告单位注销管理人登记前后实施的吸收资金行为及运营投资项目行为并无差异，不能认定其犯意发生了转化，产生了非法占有目的；被告单位已于注销登记前将所吸收资金的绝大部分投向相关项目，注销登记后仅六天即被查处，不能认定注销登记对其归还能力构成影响。被告单位被注销登记后继续以尚未清算的涉案基金名义吸收资金，与之前的非法吸收公众存款行为具有连续性、一致性，应当认定为前行为的延续。

编写人：河北省廊坊市中级人民法院 徐兵

“借故生非型”寻衅滋事行为的审查认定^①

—— 丁某、王某某寻衅滋事案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市第一中级人民法院(2024)沪01刑终538号刑事裁定书

2. 案由：寻衅滋事罪

【基本案情】

2023年5月29日凌晨，被告人丁某、王某某等人饮酒后途经上海市某娱乐场所楼下时，遇酒醉的被害人庄某某骂其说话声音大而发生口角，后被旁人劝开。丁某、王某某等人回到娱乐场所旁酒店后心生不甘，为泄愤又返回至道路寻找庄某某。丁某率先殴打庄某某，庄某某遂逃跑。丁某、王某某等人追逐庄某某至附近公路，庄某某在逃跑过程中倒地，丁某、王某某追上后一起对庄某某拳打脚踢，致庄某某身体多处受伤。经鉴定，庄某某受外力作用致肋骨骨折6处以上损伤，构成轻伤一级，另有5处伤势分别构成轻微伤。

【案件焦点】

1. 本案被告人丁某、王某某是否具有寻衅滋事的共同犯罪故意；2. 在被害人对于矛盾纠纷的引发有一定责任的情况下，被告人丁某、王某某的行为是否构成寻衅滋事罪。

^①入库案例，参见人民法院案例库2025-05-1-269-001。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：被告人丁某、王某某在公共场所共同随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，且应认定为共同犯罪。经查，丁某、王某某与被害人发生口角被旁人劝开后，心生不甘，为泄愤又返回寻找被害人，丁某率先殴打被害人，被害人遂逃跑，在被告人追逐过程中摔倒，后丁某、王某某一起对被害人拳打脚踢致其多处受伤，足以认定被告人已构成寻衅滋事罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，以寻衅滋事罪判处被告人丁某有期徒刑一年四个月；判处被告人王某某有期徒刑一年三个月。

一审宣判后，丁某、王某某提出上诉。

上海市第一中级人民法院经审理认为：原审法院根据丁某、王某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等所作出的定罪量刑并无不当，且审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点有二：一是被告人丁某、王某某是否具有寻衅滋事的共同犯罪故意；二是在被害人对于矛盾纠纷的引发有一定责任的情况下，被告人丁某、王某某的行为是否构成寻衅滋事罪。

一、寻衅滋事的共同犯意可通过明示或默示的方式形成

判断是否具有共同犯罪故意，关键在于行为人之间是否存在犯意联络。共同犯罪的犯意联络是指各行为人关于相互协同实施特定犯罪行为的意思沟通，这种意思沟通既可采用明示的方式进行，也可采用默示的方式进行，其实质上是各行为人共同实施特定犯罪行为的“合意”。

本案中，被告人丁某、王某某具有寻衅滋事的共同犯罪故意。丁某、王某

某的供述证实，其四人返回酒店后越想越气，最终决定一同下楼找被害人理论。被害人庄某某的陈述，现场监控视频，丁某、王某某的供述等证据证实，丁某、王某某等人回到路边发现被害人时，丁某先抱住被害人并掌掴其面部，王某某紧随其后，在被害人挣脱丁某的束缚欲逃跑时，王某某冲上前试图配合丁某拉住被害人。在被害人逃跑过程中，丁某、王某某等人继续追逐，至被害人摔倒在地仍未罢休，丁某先踢了被害人一脚，紧接着王某某打了被害人三拳，随后二人一同对被害人拳打脚踢，致被害人多处受伤。其间，王某某目睹丁某打人非但没有制止，反而不假思索地跟上动手，足以说明其所谓“找被害人理论”实则是争强斗狠、逞强耍横，包含随意殴打他人的犯罪故意，故二人在酒店至少已通过默示的方式形成寻衅滋事的合意。

二、被告人丁某、王某某的行为属于“借故生非型”寻衅滋事

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第二款规定：“行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为‘寻衅滋事’，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。”据此，对于“借故生非型”寻衅滋事行为是否构成寻衅滋事罪，关键在于准确判断矛盾纠纷的起因和性质，以及行为人与被害人在矛盾纠纷引发或者激化中的责任。“借故生非”，意味着即便被害人对日常生活中偶发性的矛盾纠纷也有责任，但在事态已经平息、纠纷已经中止、双方已分开的情况下，行为人为了争强斗狠、逞强耍横，仍然小题大做、借题发挥；或在冲突

过程中，特别是在双方口角时，行为人一方陡然加大侵害力度，实施与常情常理背离的随意殴打他人或者任意毁损他人财物等行为。该类案件看似事出有“因”，但“因”在常人来看非正常非正当，行为人实施的侵害行为明显不属于解决纠纷的合理方式，明显超出解决纠纷的合理限度，明显违背一般人应具备的基本是非观和普遍应遵守的道德标准，属于“借故生非型”寻衅滋事，不适用《解释》)第一条第二款规定的例外条款。

本案中，在案证据证实，案发前，被害人庄某某确实在醉酒状态下先骂丁

某、王某某等人说话大声，双方产生口角但没有肢体冲突，事态平息后双方各自离开，丁某、王某某等人回到酒店，庄某某则走到路边等车。然而，丁某、王某某等人明知纠纷已经结束，仍抓住此小事不放，并且单方面夸大矛盾纠纷的严重程度，又从酒店折返至道路寻找庄某某对其拳打脚踢，重生事端，在庄某某试图逃跑时仍追逐不舍，在其倒地后继续随意殴打、加大侵害力度，致其轻伤一级，另有五处轻微伤，对社会秩序造成严重不良影响。鉴于此，本案属于《解释》第一条第二款规定的“借故生非型”寻衅滋事，且不具有该条款规定的例外情形，依法以寻衅滋事罪论处。

编写人：上海市第一中级人民法院 阳韵

（二）共同犯罪

27

电信诈骗中起辅助作用的从犯，
以预期违法所得为限承担退赔责任

—— 陈某诈骗案